

안녕하세요, 곽준형 변리사입니다.

모두 시험치르느라 고생 많으셨습니다.

이번 시험은 문제 자체는 어렵지 않았는데 문제 지문이 길어서 난이도는 중상 정도겠습니다. 저는 제 수업 내용이 머리 속에 있는 상태에서 풀다보니 개인적인 난이도는 무난한 정도로, 중이라고 느껴졌습니다.

제가 기본, 심정최, GS에서 전부 잘 설명드렸기에, GS문제/답안만 확인하신 분들보다는 나눠드리는 자료와 함께 이론수업, GS수업을 잘 들으신 분들이라면, 문제 1-전설문, 문제 2-전설문, 문제 3-(3), 문제 4-(2)인 70점 분량의 난이도가 평이했기 때문에 충분히 다 풀 수 있던 문제들이었습니다.

(문제 2-(2), 문제 3-(3)의 20점 분량은 윤곽GS A형 8회에 거의 그대로 출제)

문제3-(1)은 문제 길이 때문에 다소 어렵게 느껴지고, 문제 3-(2), 문제 4-(1)은 문제가 묻는 바가 모호해서 어렵게 느껴졌을 수 있으나, 아주 높은 난이도는 아닙니다.

소중한 시간을 투자해서 시험준비를 하는 만큼 진정 합격을 위한 공부를 하는게 중요하겠습니다.

다들 수고많으셨고, 꼭 쉬시기 바랍니다.

[문제 1]

I. 설문(1)

**1. 문제의 소재**

**2. 건물철거청구시 건물대금과 상환으로 건물인도판결 가부**

(1) 처분권주의 의의 및 취지 [제203조]

(2) 처분권주의 내용

(3) 건물철거청구에 건물대금과 상환으로 건물인도를 구하는 청구 포함 여부 - 학판검

(4) 사안 - 포함x, 건물대금과 상환으로 건물인도판결x

**3. 법원의 적극적 석명 요부**

(1) 석명권 의의 및 취지 [제136조 제1항]

(2) 적극적 석명 허용 여부 - 학판검

(3) 사안 - 적극적 석명권 행사하여 소변경할 것 요구

**4. 원고의 소변경 적법성 (압축)**

(1) 소변경 의의 및 취지 [제262조]

(2) 소변경 적법성

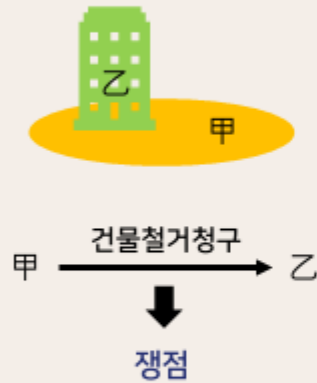
**5. 사안해결 - 법원의 판결**

적극적 석명하여 소변경 적법하게 이루어지면 건물대금과 상환으로 건물인도를 명하는 판결함

\*\*\*법원 판결을 하여야 하는지 물었기 때문에 적극적 석명도 잘 써줘야 함. 문제의 물음에 집중할 것

## II. 내용

### 4. 건물철거청구에 대해 건물대금과 상환으로 건물인도청구 포함 여부



건물대금과 상환으로  
건물인도하라는 판결 가부

#### (1) 문제점

원고가 건물철거청구를 구한 취지에 건물대금과 상환으로 건물인도를 구하는 취지도 포함되어 있는지 문제

#### (2) 학설

##### 1) 긍정설

근거: 원고는 패소판결을 받기보다는 **상환이행판결이라도 받겠다는 의사**

결과: 포함O

##### 2) 부정설

근거: 청구취지 및 청구원인이 다름

결과: 포함X

#### (3) 判例

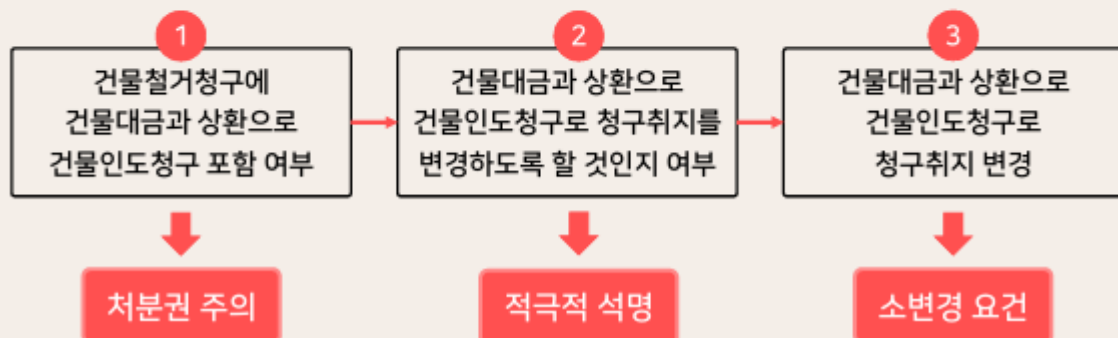
건물철거청구에는 건물매매대금과 동시에 건물명도를 구하는 청구가 포함되어 있지 않음

#### (4) 검토 - 강제집행 차이, 석명권으로 해결 가능 포함X

## II. 내용

### 4. 건물철거청구에 대해 건물대금과 상환으로 건물인도청구 포함 여부

[문제 Flow]



## II. 설문(2)

### 1. 문제의 소재

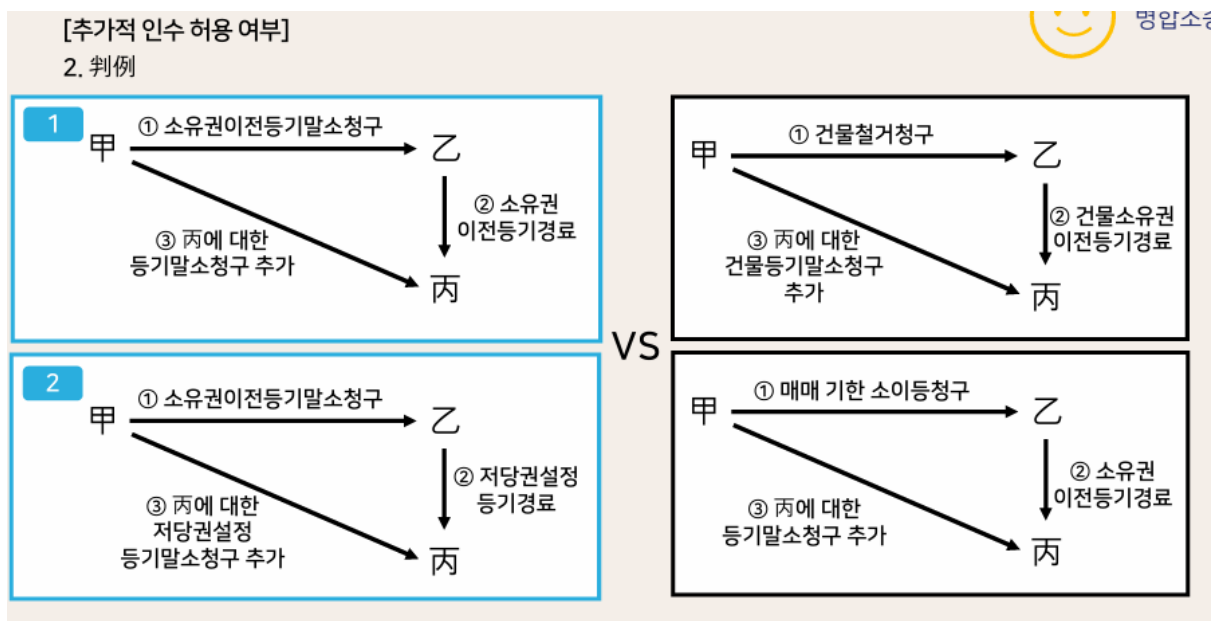
### 2. 인수승계 의의 및 취지 [제82조]

### 3. 인수승계 요건

### 4. 추가적 인수 가부 - 학판검

### 5. 사안해결

추가적 인수 불가, 청구권의 주장 자체로 신청이 부적법한바, 각하결정



[추가적 인수 허용 여부]

1. 判例

3

甲 1 ① 공유물분할청구 → 甲 2

甲 3

② 乙, 丙을 추가?

乙 (소송 중 甲 2로부터 甲 2의 지분의 30% 양수)

丙 (소송 중 甲 2로부터 甲 2의 지분의 35% 양수)

i) 공유물분할청구소송의 소송계속 중

ii) 공유자 가운데 한사람으로부터 그 사람의 지분 일부를 이전받은 제3자를 피고로 추가하는 것은

iii) 추가적 인수로 허용된다.

[보너스]

고필추가(제68조)로 하자치유 가능할까?

[주의]

고필추가는 1심까지만 소송승계(추가적인수 등)는 2심까지

2. 학설

(1) 긍정설

근거: 분쟁 주체의 지위가 이전되었음

결론: 추가적 인수를 긍정

(2) 부정설

근거: 소송으로 끌어들이지는 제3자는 소송목적의 아닌 별개의 채무를 집

결론: 추가적 인수를 부정

3. 검토

분쟁의 종국적 해결을 위해

소송목적의 권리·의무 전 일부를 승계했다고 볼 수 있다면 추가적 인수를 허용함이 타당

1. 문제의 소재

2. 공동소송형태 - 고필

3. 고필 1인 누락시 취급

4. 인수승계로 하자 치유

(1) 인수승계 의의 및 취지

(2) 인수승계 요건

(3) 추가적인수 가부 -학판검사

5. 고필추가로 하자 치유

(1) 고필추가 의의 및 취지

(2) 고필추가 요건

6. 사안해결

### Ⅲ. 설문(3)

#### 1. 문제의 소재

#### 2. 기판력 의의 및 취지

#### 3. 기판력 시적범위 및 차단효

#### 4. 전소 변론종결 전 존재한 형성권의 차단 여부 - 학판검

#### 5. 사안해결

건물매수청구권 비실권설 지지, 기판력에 저촉되지 않고, 적극적 석명권 행사하여 건물대금과 상환으로 건물을 인도하라는 판결

#### Ⅱ. 변론종결 전 사유의 차단

##### 2. 변론종결 전 형성권

##### (1) 문제점

전소 변론종결 전 존재한 취소권, 해제권, 상계권, 건물매수청구권 등 형성권을 후소에서 주장시 기판력 의해 차단?

##### (2) 학설

| 학설                             | 근거                                                             | 결론                                                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 실권설                            | 법적안정성                                                          | 모든 형성권이 차단 O                                                       |
| 비실권설                           | 실체법상 권리인 형성권의 행사를 존중                                           | 모든 형성권이 차단 X                                                       |
| 상계권<br>(또는 건물매수청구권)<br>비실권설    | 상계항변은 출혈적 방어방법,<br>행사시키는 자유<br>(건물매수청구권은<br>건물효용유지 위해 정책적 마련됨) | 다른 형성권은 후소에서 차단 O<br>상계권(또는 건물매수청구권)은<br>차단 X                      |
| 제한적 상계권<br>(또는 건물매수청구권)<br>실권설 | 소송촉진 및 신의칙 준수                                                  | 상계권(건물매수청구권)도<br>전소 변론종결전 행사할 수<br>있었음을 알았는데<br>불행사한 경우, 후소에서 차단 O |

##### <형성권이란?>

권리자의 일방적인 의사표시에 의하여 새로운 법률관계의 형성, 즉 권리의 발생, 변경, 소멸 등의 일정한 법률효과를 발생시키는 권리

##### (3) 判例

##### 1) 취소권, 해제권, 백지보충권

① 해제사유가 전소의 변론종결 전에 존재했다면

② 변론종결 후에 해제의 의사표시를 했더라도 기판력에 저촉됨

##### 2) 상계권

① 변론종결 후 상계의사표시를 한 때에는

② 청구이의의 소에서 규정하는 이의원인이 변론종결 후에 생긴 때에 해당하므로

③ 양 채권이 변론종결 전에 상계적상에 있었어도 알았는가 몰랐는가와 무관하게  
적법한 청구이의사유가 됨

##### 3) 건물매수청구권

① 확정판결에 의하여 건물철거가 집행되지 않은 이상 임차인은 매수청구권을

행사하여 별소로 임대인에 대해 건물매매대금지급을 구할 수 있음

② 건물철거소송과 매매대금청구소송은 서로 소송물을 달리하므로

③ 종전 확정판결의 기판력에 의해 건물매수청구권의 행사가 차단 X

[문제 2]

I. 설문(1)

**1. 문제의 소재**

**2. 甲, 丙, 丁의 공동소송관계**

(1) 공동소송의 형태 - 고/유/통

(2) 통공 독립 원칙 - [제66조]

(3) 사안 - 공동상속인인 甲, 丙, 丁은 통공관계, 각자 독립적으로 소송수행

**3. 소송 중 사망**

(1) 당사자 지위 당연승계 여부 - 학판검

(2) 절차 중단 및 수계 - 소송대리인 없을 때 곧바로 중단

**4. 공동상속인 중 일부만의 수계신청 가부**

(1) 수계신청 의의 및 취지

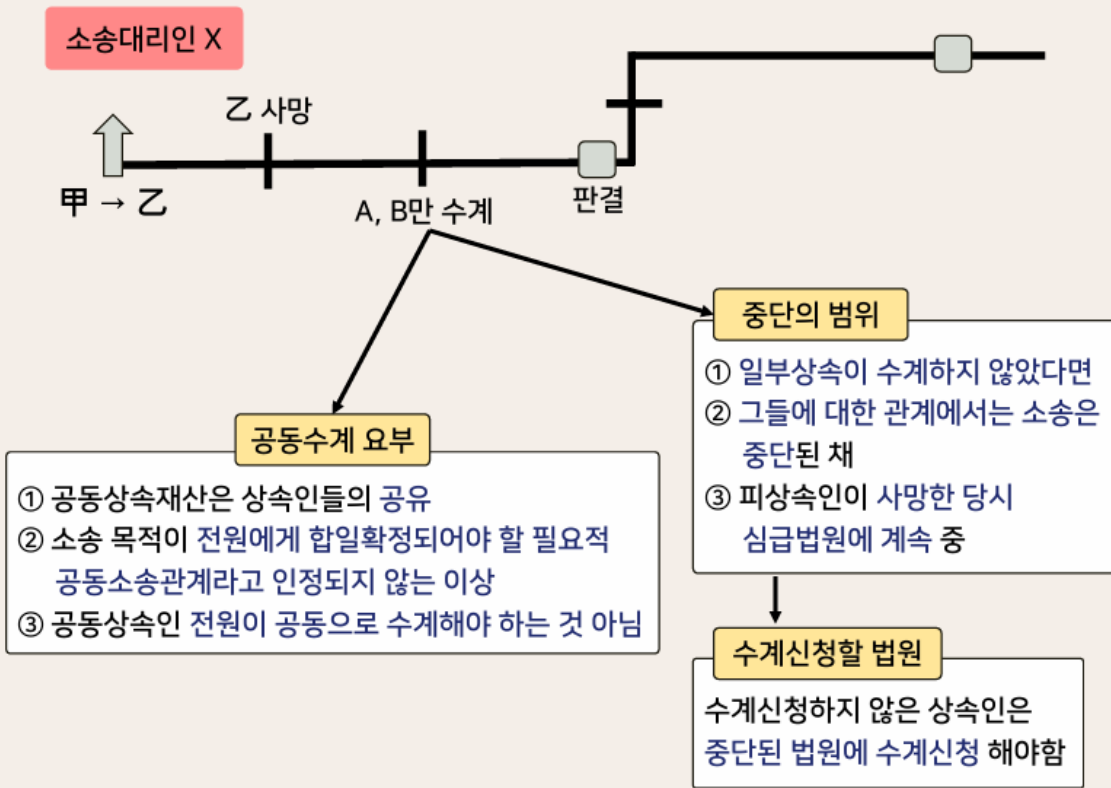
(2) 사안 - 통공 독립원칙에 따라 甲만 단독으로 수계 가능

**5. 丙, 丁의 소송관계**

당사자지위 당연승계, 소송대리인 없으므로 A사망시 절차 중단된 상태(판결x)

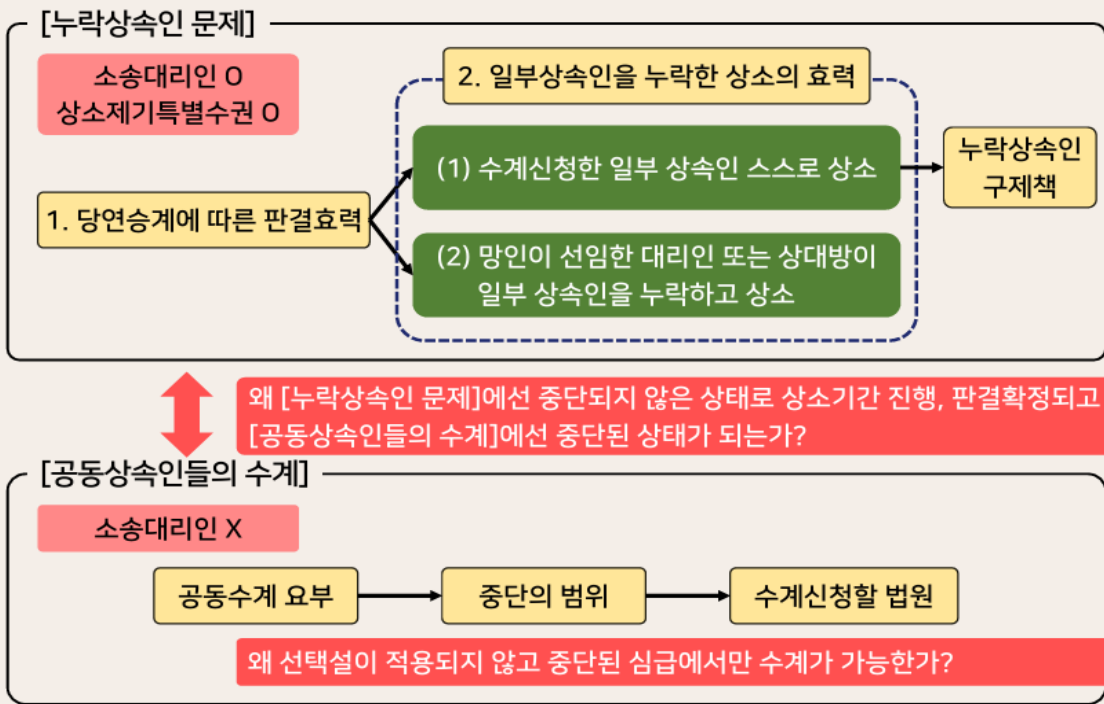
#### IV. 관련논점

##### [공동상속인들의 수계]



#### IV. 관련논점

##### [누락상속인 SET & 공동상속인들의 수계]



## II. 설문(2)

### 1. 문제의 소재

### 2. 소변경 및 부대항소 의의 및 취지, 요건(분량상 매우 압축 또는 생략)

### 3. 재소금지원칙 의의 및 취지 [제267조 제2항]

### 4. 재소금지원칙 요건

### 5. 소취하한 당사자에 변론종결 후 특정승계인 포함 여부

(1) 학판검

(2) 사안 - 포함

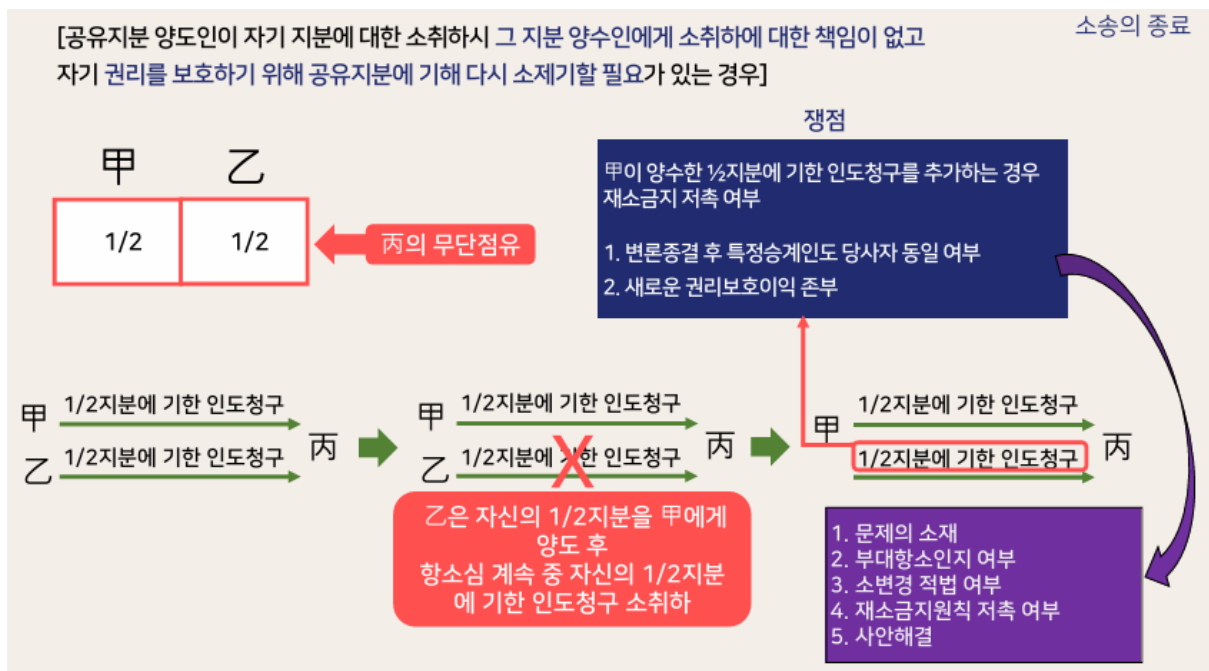
### 6. 새로운 권리보호이익 인정 여부

(1) 새로운 권리보호이익 의의

(2) 사안 - 소취하 책임 없고 다시 소제기할 필요성 있는바 새로운 권리보호이익 인정

### 6. 사안해결

소변경이자, 부대항소이며, 당사자 요건 관련하여 재소금지 효과 미칠 수 있으나, 새로운 권리보호이익 있어서 재소금지에 저촉되지 않음





[문제 3]

I. 설문(1)

**1. 문제의 소재**

**2. 주위적 청구에 대한 판단**

(1) 환송판결의 기속력 의의 및 취지

(2) 내용

(3) 예외

(4) 효과

(5) 사안 – 새로운 사실과 증거 채택 없이 환송 전 원심판결과 동일한 판단을 하여 환송 판결 기속력에 반한 잘못이 있음

**3. 예비적 청구에 대한 판단**

(1) 소변경 및 예비적 병합 (압축)

(2) 제척기간 도과 여부 (압축)

(3) 지적의무 의의 및 취지, 내용 (압축)

(4) 사안 – 예비적 청구 추가의 소변경 요건은 갖추어 예비적 병합이 될 수 있고, 제척기간 도과되어 각하될 수 있으나, 각하시 지적의무 행사할 것

**4. 사안해결**

## I. 의의 및 성질

환송받은 법원이 재판하는 경우, 상고심이 파기이유로 한 사실상 및 법률상 판단에 기속  
(제436조 2항)

+ 심급제도 유지를 위한 특수적 효력

## II. 내용

- 1. 객관적 범위
- 2. 주관적 범위

- (1) 사실상 판단
- (2) 법률상 판단

## III. 예외

- 1. 판례변경
- 2. 사실관계 변동
- 3. 법령 변경

## IV. 효과

일반적 상고이유

## II. 내용

언제 쓰나?

### 1. 객관적 범위

#### (1) 사실상 판단

- ① 직권조사사항, 절차위배, 재심사유에 대한 사실존부 판단
- ② 본안에 관한 사실판단은 이에 해당되지 않는다.

#### (2) 법률상 판단

법령의 해석 및 적용, 사실에 대한 법적 평가

### 2. 주관적 범위

- ① 환송받은 법원, 그 하급심, 재상고법원 모두 기속된다.
- ② 다만, 전원합의체는 이에 포함되지 않는다.

## III. 예외

환송 후 상고심의 [판]례변경이 있는 경우,  
기속적 판단의 기초가 된 [사]실관계에 변동이 생긴 경우,  
환송 후 [법]령의 변경이 있는 경우는 환송판결의 기속력이 소멸한다.

(1) 소송요건

1) 당사자적격 - 피고적격/원고적격 ★

2) 제소기간

3) 부제소합의

4) 청구취지 불특정

<고수의 TIP>

청구취지에 대한 소극적 석명으로 볼 수도 있음

5) 확인의 이익★

6) 대표권

+ 비법인 사단 명의의 소제기시 총회결의를 거쳐  
소제기에 관한 특별수권 존부에 대해 밝혀보고 소각하

SET

직권조사사항인지 여부



흡결시 지적의무 행사하고  
소각하해야하는지 여부

## II. 설문(2)

### 1. 문제의 소재

### 2. 제2 사해행위취소소송의 적법성 (압축)

(1) 중복소제기 의의 및 취지, 요건 [제259조]

(2) 사안 - 피보전권리 달라도 동일 사해행위에 대한 취소를 구하면 소송물 동일하므로 후소인 제2 사해행위취소소송은 중복소 위반으로 부적법

### 3. 소취하 의의 및 취지

### 4. 소취하 요건

### 5. 소취하 효과

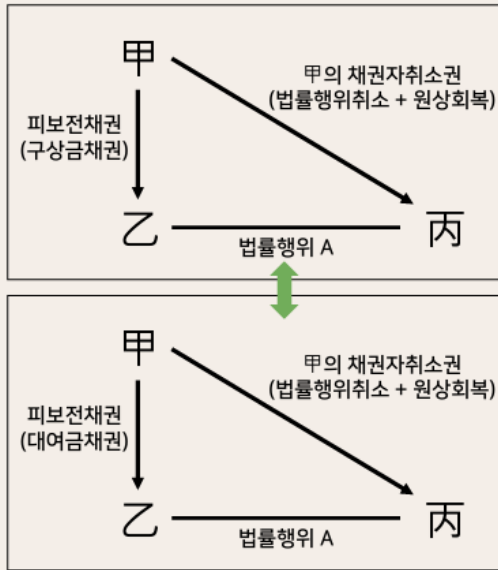
### 6. 사안해결

부적법한 소도 취하할 수 있으나, 피고가 제출한 준비서면이 본안에 관한 것이라면, 피고의 동의 없이는 소취하 효력 발생하지 않고, 동의 받아야만 소취하 효력 발생

\*\*\*소취하 효력을 물었기 때문에 중복소보다는 소취하 내용에 비중을 실어주는게 바람직

### III. 피보전채권 추가 및 변경

사해행위취소소송



#### <고수의 TIP>

앞서 사해행위취소소송의 법적성질 간략히, 소송물이 무엇인지 간략히 언급

- i) ① 채권자가 사해행위취소 및 원상회복청구를 하면서 보전하고자 하는 채권을 추가하거나 교환하는 것은
- ② 사해행위취소권과 원상회복청구권을 이유 있게 하는 공격방법에 관한 주장을 변경하는 것일 뿐이지
- 소송물 자체를 변경하는 것 X
- ii) ① 채권자가 보전하고자 하는 채권을 달리하여 동일한 법률행위의 취소 및 원상회복을 구하는 채권자취소의 소를 이중으로 제기하는 경우
- ② 전소와 후소는 소송물이 동일하다고 보아야 하고,
- ③ 이는 전소나 후소 중 어느 하나가 승계참가신청에 의해 이루어진 경우에도 마찬가지

1. 문제의 소재
2. 사해행위취소소송 의의 및 취지
3. 사해행위취소소송 법적 성질 및 소송물
4. 피보전채권 추가 및 변경시 소송물을 달리하는지 여부
5. 사안해결

### I. 의의 및 취지

소송의 종

원고가 제기한 소의 전·일부를 철회하는 것으로 소송계속이 소급소멸됨  
+ 당사자의 처분권을 존중

원고 vs 피고  
항소인 vs 피항소인

### II. 요건

항소취하는 항소심 중국판결 전까지

- i) 판결 확정 전까지 ii) 소송능력 등 소송행위 유효요건 갖출 것
- iii) 피고가 본안에 대한 준비서면의 제출 또는 변론준비기일에서의 진술, 변론을 한 경우 그의 동의 要

항소취하는 피항소인 동의 不要

### III. 절차

서면 / 말 가능

[소취하서 제출 후 임의철회 가능]

소취하서가 제출되면 그 서면이 상대방에게 송달되기 전후 불문 임의 철회 불가

[관련 논점]

1. 상대방의 동의가 필요 없는 경우
2. 소취하 동의에 대한 별도의 특별수권 요부

### IV. 효과

항소취하는 항소심만 소급소멸  
1심판결은 존재함

항소기간 도과 전

항소기간 도과 후

1. 소송계속 소급소멸
2. 재소금지 효력

#### <고수의 TIP>

소취하 간과 심리 속행시 → 당사자 이의(직권발동 촉구) → 법원 직권으로 소송종료선언

### Ⅲ. 설문(3)

#### 1. 문제의 소재

#### 2. 원심재판장의 항소장심사권

(1) 원심재판장의 항소장에 대한 보정명령

(2) 원심재판장의 항소장각하명령

#### 3. 소송대리인에 대한 항소장 보정명령

(1) 소송대리권의 범위 [제90조 제1항 및 제2항]

(2) 특별수권이 있는 소송대리인에 대한 보정명령 가부

1) 원칙 - 최판

2) 예외 - 소송대리인이 아닌 당사자 본인이 항소장 제출한 경우 - 최판

#### 4. 사안해결

항소장각하명령 위법

항소법원으로 보내야 한다(제400조).

#### ☑ 상소제기 특별수권 있는 소송대리인에 대한 상소장 인지보정명령

1. 상소제기 특별수권 있는 소송대리인에게 보정명령 가부

상소 제기 특별수권이 있다면 소송대리인은 상소장을 제출할 권한이 있으므로, 상소장에 인지를 붙이지 않은 흠이 있다면 소송대리인은 이를 보정할 수 있고 원심재판장도 소송대리인에게 인지의 보정을 명할 수 있다.

2. 당사자 본인이 상소장을 작성하여 제출한 경우 소송대리인에 대한 보정명령 효력

소송대리인의 상소제기 특별수권이 있더라도, 실제로 소송대리인이 아닌 당사자 본인이 상소장을 작성하여 제출한 경우, 소송대리인에게 상소장과 관련한 보정명령을 수령할 권능이 없으므로, 원심재판장이 소송대리인에게 보정명령을 송달한 것은 부적절한 송달이어서 그 송달의 효력이 발생하지 아니한다(2023마7122).

#### ☑ 상소인이 인지보정명령에 대해 인지액에 해당하는 현금을 송달료로 납부한 경우

상소인이 인지의 보정명령에 따라 인지액에 해당하는 현금을 수납은행에 납부하면서 잘못하여 인지로 납부하지 않고 송달료로 납부한 경우에는 인지가 납부되었다고 할 수 없어 인지 보정의 효과가 발생하지 않으나 상소인에게 인지를 보정하는 취지로 송달료를 납부한 것인지에 관하여 석명을 구하고 다시 인지를 보정할 수 있는 기회를 부여해야 한다(2020마7755).

(2) 항소심재판장

## 최신判例 - 상소제기 특별수권 있는 소송대리인에 대한 상소장 보정명령(2023 마7122)

### 결정요지

소송대리권의 범위는 원칙적으로 당해 심급에 한정되지만, 소송대리인이 상소 제기에 관한 특별한 권한을 따로 받았다면 특별한 사정이 없는 한 상소장을 제출할 권한과 의무가 있으므로, 상소장에 인지를 붙이지 아니한 흠이 있다면 소송대리인은 이를 보정할 수 있고 원심재판장도 소송대리인에게 인지의 보정을 명할 수 있다. 그러나 소송대리인이 상소 제기에 관하여 특별한 권한을 따로 받았다고 하더라도, 실제로 소송대리인이 아닌 당사자 본인이 상고장을 작성하여 제출한 경우에는 소송대리인에게 상소장과 관련한 보정명령을 수령할 권능이 없으므로, 원심재판장이 소송대리인에게 보정명령을 송달한 것은 부적법한 송달이어서 그 송달의 효력이 발생하지 아니한다.

1. 소송대리권의 범위는 원칙적으로 당해 심급에 한정되지만, 소송대리인이 상소 제기에 관한 특별한 권한을 따로 받았다면 특별한 사정이 없는 한 상소장을 제출할 권한과 의무가 있으므로, 상소장에 인지를 붙이지 아니한 흠이 있다면 소송대리인은 이를 보정할 수 있고 원심재판장도 소송대리인에게 인지의 보정을 명할 수 있다(대법원 2013. 7. 31. 자 2013마670 결정 참조). 그러나 소송대리인이 상소 제기에 관하여 특별한 권한을 따로 받았다고 하더라도, 실제로 소송대리인이 아닌 당사자 본인이 상고장을 작성하여 제출한 경우에는 소송대리인에게 상소장과 관련한 보정명령을 수령할 권능이 없으므로, 원심재판장이 소송대리인에게 보정명령을 송달한 것은 부적법한 송달이어서 그 송달의 효력이 발생하지 아니한다(대법원 2016. 12. 27. 자 2016무745 결정 참조).

2. 기록에 의하면, 재항고인은 원심인 서울동부지방법원 2021나35143 사건에서 2023. 5. 12. '제1심판결을 취소하고 재항고인의 청구를 기각한다.'는 내용의 판결을 선고받고, 2023. 5. 26. 재항고인 본인이 상고장을 작성하여 제출한 사실, 원심재판장은 2023. 5. 31. '이 명령을 송달받은 날부터 7일 안에 인지대 및 송달료를 납부하라.'는 내용의 보정명령(이하 '이 사건 보정명령'이라고 한다)을 발령하면서, 이를 재항고인의 원심 소송대리인인 변호사 소외인에게 송달하였을 뿐 재항고인 본인에게 송달하지 않은 사실, 원심재판장은 2023. 7. 10. 재항고인이 위 기간 내에 인지를 보정하지 않았다는 이유로 상고장 각하명령을 한 사실, 한편 재항고인은 위 변호사 소외인에게 소송대리를 위임하면서 상소 제기에 관한 특별한 권한을 부여한 사실을 알 수 있다.

위와 같은 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 재항고인의 원심 소송대리인이 상소 제기에 관한 특별한 권한을 따로 받았다고 하더라도 실제로 원심 소송대리인이 아닌 재항고인 본인이 상고장을 작성하여 제출하였으므로, 재항고인의 원심 소송대리인은 상고장과 관련한 보정명령을 수령할 권능이 없다. 따라서 원심이 재항고인의 원심 소송대리인에게 보정명령을 송달한 것은 부적법한 송달이어서 그 송달의 효력이 발생하지 아니하였고, 결국 이 사건 보정명령에서 정한 보정기간이 진행하지 않게 된다.

3. 그런데도 원심재판장은 재항고인이 이 사건 보정명령에서 정한 기간 내에 부족한 인지를 보정하지 않았다는 이유로 상고장을 각하하는 명령을 하였다. 이러한 원심명령에는 소송대리권의 소멸 및 송달에 관한 법리를 오해하여 재판에 영향을 미친 위법이 있다.

[문제 4]

I. 설문(1)

**1. 문제의 소재**

**2. 기판력 의의 및 취지**

**3. 기판력 주관적 범위**

(1) 원칙 – 상대성원칙

(2) 예외

**4. 변론종결 뒤일 것**

(1) 채권양도의 경우 – 대항요건 갖춘 기준

(2) 사안 – 대항요건이 변론종결 뒤에 이루어져 변론종결 뒤 승계인

**5. 승계인에 해당할 것**

(1) 소송물 및 계쟁물

(2) 사안 – 소송물 자체를 승계하여 승계인 해당

**6. 객관적 범위 및 작용국면 (압축)**

**7. 시적범위 및 차단효 (압축)**

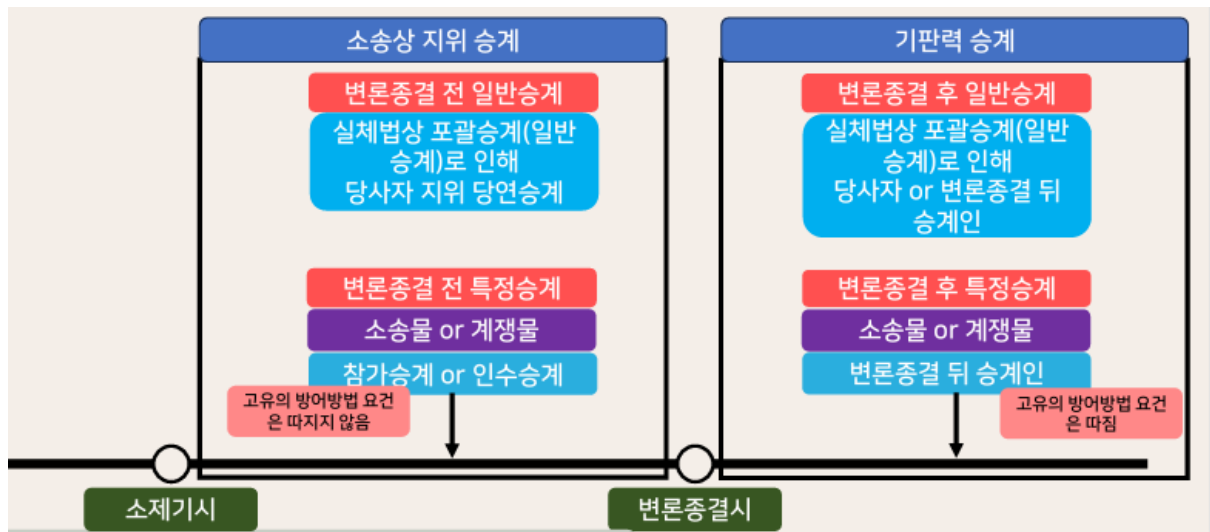
**8. 기판력 본질 (압축 또는 생략)**

**9. 사안해결**

전소 승소확정판결에 의해 권리보호이익 흠결로 각하

\*\*\*후소 판단을 물었고, 결국 변론종결 뒤 승계인이 되므로 전소에 참가한 것은 굳이 논할 실익이 없음





## II. 변론종결 뒤 승계인 승계집행문을 받아 판결을 집행할 수 있다(민사집행법 제31조).

### 1. 의의 및 취지

확정판결은 변론을 종결한 뒤의 승계인에 대하여 효력이 미친다(제218조 1항).

판결효력의 회피를 방지하기 위함

### 2. 변론종결 "뒤"의 승계일 것

#### (1) 물건 승계

1) 등기가 이루어진 시점 기준

2) 건물철거청구 사건에서 변론종결 전 가등기를 하고 변론종결 후 본등기를 마친 사람은

변론종결 뒤 승계인에 해당한다고 보았다(92다10883). 다만, 말소등기청구 사건에서

변론종결 전 가등기를 마치고 변론종결 후에 본등기를 마친 사람은 변론종결 뒤의 승계인에

대당하지 않는다고 보았다(69다2227). → 전자는 건물의 철거의무를 지는 사실상의 건물 처분권

취득시점에 중점을 둔 것이고 후자는 가등기의

순위보전적 효력에 중점을 둔 것이다(전원열)

#### (2) 채권 승계

① 채권양수인이 변론종결 뒤 승계인에 해당하는지 여부는

② 채권양도합의가 아닌 대항요건이 갖추어진 때를 기준으로 판단한다

#### (3) 2차 승계

① 1차 승계가 변론종결 전이라면 2차 승계가 변론종결 뒤라도

② 2차 승계인은 변론종결 뒤 승계인에 해당하지 않는다.

## II. 변론종결 뒤 승계인

### 3. 승계인에 해당할 것

채권양수인 또는 면책적 채무인수인은 소송물 승계인에 해당한다.

다만, 중첩적으로 채무를 인수한 자는 당사자의 채무는 그대로 존속하며 별개의 채무를 부담하는 것이므로 승계인에 해당하지 않는다(2009그196). 또한, 영업양수인도 승계인에 해당하지 않는다.

#### (1) 소송물 승계

소송물 자체를 승계한 자는 채권 또는 물건인지 여부를 불문하고 승계인에 해당

#### (2) 계쟁물 승계

언제 쓰나?

##### 1) 학설

i) 구이론 - 소송물이 대세적 효력이 있는 물건적 청구권인 경우에만 승계인

ii) 신이론 - 실체법상 권리와 분리해 소송물 판단하므로 물건적/채권적 청구권을 불문하고 승계인

##### 2) 判例

① 소유권에 기한 등기말소청구와 같은 물건적 청구권인 경우에만

② 원고승소확정판결 후에 피고로부터 이전등기를 경료한 자는

③ 원고에게 등기말소 의무를 부담하므로 변론종결 뒤의 승계인

##### 3) 검토

소송물이 채권적 청구권인 경우, 승계인은 원고에게 아무런 의무 부담 X

→ 물건적 청구권인 경우에만 승계인



## II. 설문(2)

### 1. 문제의 소재

### 2. 보조참가 의의 및 취지 [제71조]

### 3. 보조참가 요건 (압축)

(1) 소송결과 이해 관계 - 학판검

(2) 사안 - 적법

### 4. 보조참가 효과 - 참가인의 지위

(1) 독립적 지위

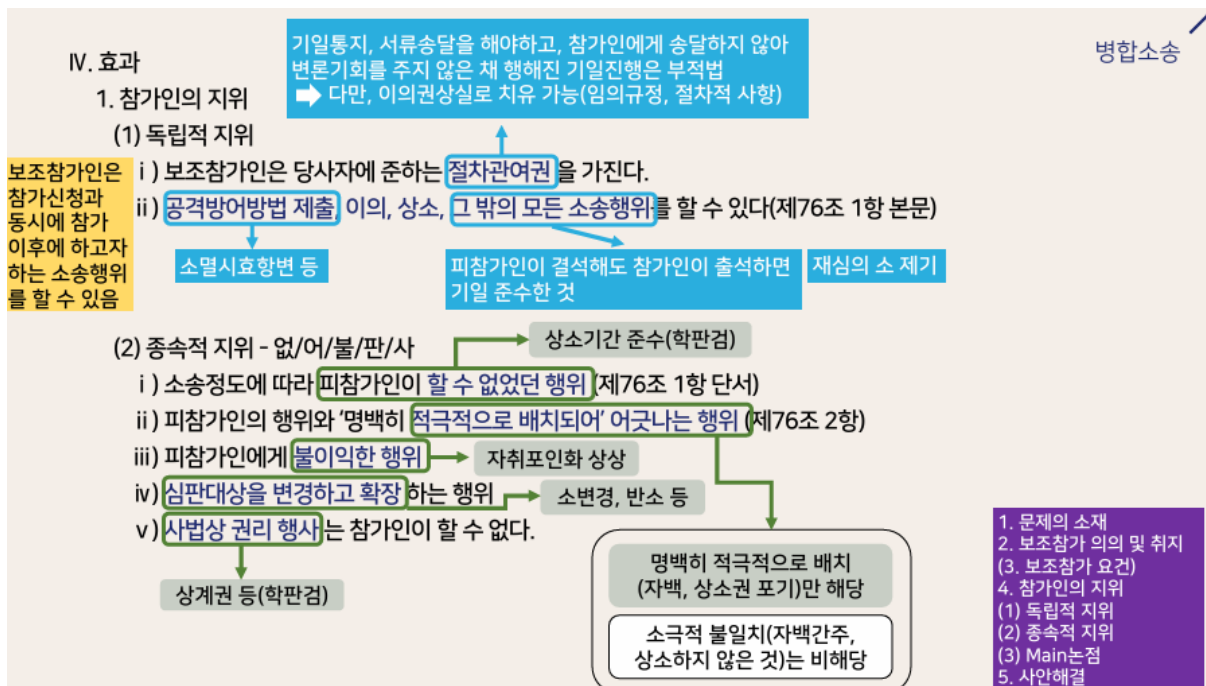
(2) 종속적 지위

(3) 상소기간 준수 판단 - 학판검

(4) 사안 - B는 독립적 지위로 항소 가능, 다만, 피참가인 항소기간에 종속되어 항소기간 도과로 항소 부적법

### 5. 사안해결

丙의 항소는 항소기간 도과로 부적법, B의 항소도 가능은 하지만, 결국 항소기간 도과로 부적법 (항소장각하명령도 가능)



[보조참가인의 상소기간]

1. 학설

(1) 다수설 - 근거 : 보조참가인의 **종속적** 지위를 강조

결론 : 피참가인의 상소기간 내에만 상소가 가능

(2) 소수설 - 보조참가인의 **독립적** 지위를 강조하여, **상소하여 판결의 승패를 바꿀 수**

**있음에도** 이를 불허하면 별도로 다투게 되어 **소송경제에 부합하지** 않음

결론 : 보조참가인의 상소기간 내려면 상소가 가능

2. 判例

보조참가인이 **자신이 판결을 송달받은 날부터 기산하여 2주 내에** 상고한 사건에서

**피참가인의 상고기간을 어긴 때는 참가인의 상고 역시 상고기간 경과의 것으로**

**부적법하다**(2007다41966).

3. 검토

**제76조 1항 단서**에서 피참가인이 할 수 없었던 행위는 참가인도 할 수 없다고 규정하는

취지에 비추어 다수설이 타당하다.

[명문의 규정 없는 피참가인의 사법상 권리행사]

1. 학설

(1) 다수설

근거 : 보조참가인의 **종속적** 지위를 강조

결론 : 피참가인의 사법상 권리 행사 **不可**

(2) 소수설

근거 : 보조참가인의 **독립적** 지위를 강조

결론 : 피참가인에게 유리한 결과를 가져올 수 있으므로 그의 사법상 권리 행사 가능

2. 검토

① **명문의 규정 X**

② **사법상 권리 행사**는 당사자의 자유에 맡겨야 하므로 다수설이 타당